

النظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية دراسة مقارنة

د/ ماجد ملفي زايد الديحاني

دكتوراه في القانون العام ، عضو هيئة تدريس منتدب بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت

إن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي لإشباع الحاجات العامة، ترتب عليه ظهور المرافق العامة الاقتصادية للقيام بهذا الدور الهام في حياة الأفراد اليومية، إذ تقوم هذه المرافق على توفير الكثير من الخدمات الحيوية كالإمداد بالكهرباء والماء والوقود، والاتصال والنقل وغيرها من الخدمات الضرورية.

ولا شك في أن قيام هذه المرافق لهذا الدور الهام السابق ذكره، أدى إلى إثارة التساؤل حول طبيعة أموال تلك المرافق وما إذا كانت أموال عامة أم أموال خاصة.

فالنظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي يختلف تبعاً لاختلاف طبيعة أموال المرفق، فهذه الأخيرة ليست كلها على درجة واحدة، فقد تكون أموالاً عامة (الدومين العام)، وقد تكون مالاً خاصاً تملكها المرافق ملكية عادية كملكية الأفراد لأموالهم ويطلق عليها (الدومين الخاص).

وتخضع أموال الدومين الخاص لذات القواعد التي تخضع لها أموال الأفراد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن ناحية أخرى يختلف النظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي تبعاً لتنوع طريقه إدارته، سواء بطريقة الاستغلال المباشر، أو بطريقة المؤسسات والهيئات العامة.

أهمية الدراسة:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى التزايد الكبير لاستخدام أفراد المجتمع للمرافق العامة الاقتصادية، بحيث أصبح من الصعب استغناء الفرد عن خدماتها، بل يعتمد عليها في حياته اليومية، ويتم من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات، ولا شك في أن هذه الأهمية للمرافق العامة الاقتصادية تعطي أهمية لدراسة النظام القانوني لأموال هذه المرافق.

وترجع أيضاً أهمية دراسة النظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية لمعرفة وتحديد طبيعة أموال تلك المرافق، وما إذا كانت أموال عامة أم أموال خاصة، فهذا النظام القانوني يختلف تبعاً لاختلاف طبيعة أموال المرفق، فقد تكون أموالاً عامة، وقد تكون مالاً خاصاً تملكها المرافق ملكية عادية كملكية الأفراد لأموالهم، وبالتالي تخضع لذات القواعد التي تخضع لها أموال الأفراد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن ناحية أخرى يختلف النظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي تبعاً لتنوع طريقه إدارته، وهذا يعطي أيضاً أهمية لدراسة النظام القانوني لهذه الأموال، نظراً لأهمية ما يعد من أموال المرفق العام مالاً عاماً وما لا يعد كذلك، وترجع أيضاً أهمية هذه الدراسة لقلة من بحث وكتب في هذا المجال، بالرغم من أهمية المرافق العامة الاقتصادية والدور الذي تلعبه

في النشاط الاقتصادي للدولة، وهذا ما دفعني إلى سبر أغوار هذا النظام القانوني من خلال هذه الدراسة. مشكلة الدراسة وتساؤلاتها والهدف منها:

إن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي لإشباع الحاجات العامة، ترتب عليه ظهور المرافق العامة الاقتصادية للقيام بهذا الدور الهام، وهذا أدى إلى إثارة بعض التساؤلات القانونية حول النظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية، سواء المتعلقة بطبيعة أموال تلك المرافق وما إذا كانت أموال عامة أم أموال خاصة، والقواعد الخاضعة لها هذه الأموال والمعيار المميز لها، والتطور الذي لحق بهذا النظام القانوني، ومدى تأثير الخصخصة على رقابة الدولة لهذه الأموال، سواء عن طريق الرقابة البرلمانية والرقابة المالية. ولاشك في أن الهدف من هذه الدراسة هو البحث المستفيض للنظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي، والإجابة على كل هذه التساؤلات القانونية المفروضة من خلال هذه الدراسة.

نطاق الدراسة:

أما عن نطاق الدراسة فقد اقتصرت دراستنا فيما يتعلق بالنظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية دون غيرها من أنواع المرافق العامة الأخرى، بوصف هذه المرافق العامة الاقتصادية أكثر أهمية وشيوعاً في الوقت الحاضر، لتقديمها الخدمات الحيوية، وكذلك كل ما يتعلق بالنظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي في كل من فرنسا والكويت ومصر.

منهجية الدراسة:

سنبدأ باعتماد المنهج الوصفي عند تناول تعريف المرافق العامة الاقتصادية وذكر عناصرها، وكذلك عند تعريف الخصخصة وتأثير الخصخصة على رقابة الدولة لأموال المرافق العامة الاقتصادية، ثم سنلجأ إلى المنهج التحليلي في تناول الطبيعة القانونية لأموال المرافق العامة الاقتصادية، والاتجاهات الفقهية بشأن هذه الأموال، هذا وأثرت أن تكون هذه الدراسة مذيبة بالمنهج المقارن، وذلك لما له من فوائد عديدة، فهو يساعد على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، فلذلك تم التركيز في هذه الدراسة على الوضع في كل من فرنسا ومصر حيث تأخذان بنظام قضائي مزدوج، والكويت حيث تأخذ بنظام قضائي موحد، وذلك بخصوص النظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية.

خطة الدراسة:

وبناءً على ما تقدم وتحقيقاً للهدف المنشود من الدراسة، وجدنا من المناسب أن نقسم هذه الدراسة على النحو التالي:

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لأموال المرافق العامة الاقتصادية.

المبحث الثاني: القواعد الخاضعة لها أموال المرافق العامة الاقتصادية.

المبحث الثالث: تأثير الخصخصة على رقابة الدولة لأموال المرافق العامة الاقتصادية.

المبحث الأول الطبيعة القانونية لأموال المرافق العامة الاقتصادية

إن المرافق العامة الاقتصادية هي التي تقوم على أساس مزاوله نشاط من جنس الأفراد، ومن أمثلتها مرافق النقل بالسكك الحديدية أو الطائرات أو السيارات، والتلغراف والبريد والتليفونات وتوريد المياه والغاز والحمامات العمومية والمسارح والسينما (١).

وأما بالنسبة للعناصر التي تقوم عليها المرافق العامة الاقتصادية هي ذاتها التي تقوم عليها المرافق العامة، ويرى البعض أن العناصر المميزه للمرافق العامة، ثلاثة منها متفق عليها، والعنصر الرابع اختلف الفقه في شأنه (٢)، وهذه العناصر هي:

١. المرافق العامة الاقتصادية من إنشاء السلطة العامة.
 ٢. تحقيق النفع العام.
 ٣. خضوع المرافق العامة الاقتصادية لإشراف الدولة.
 ٤. عدم استهداف الربح بصفة أصلية في المرافق العامة الاقتصادية (٣).
- هذا وفيما يتعلق بشأن أموال المرافق العامة الاقتصادية فقد اختلف الفقه تبعاً لتنوع طريقة إدارة هذه المرافق، فرأى البعض (٤) الأخذ بنظرية ازدواج الملكية حيث تكون للدولة ملكية رقبة، بينما تكون للمرفق حق الإنتفاع، وذهب البعض الآخر (٥) للأخذ بنظرية ملكية المشروعات لهذه الأموال ما دامت تدير هذه المرافق لحسابها. وقد قام القضاء الفرنسي بتبني هذه النظرية في العديد من أحكامه، ثم عدل عنها بعد ذلك وأخذ بنظرية ملكية المشروع، ولذلك ينبغي التطرق لإتجاهات الفقه سواء في فرنسا أو مصر أو الكويت، ثم نخرج بعد ذلك على المعيار الذي تبناه المشروع والقضاء في هذه الدول، وذلك وفقاً للترتيب والتقسيم التالي:

المطلب الأول الاتجاهات الفقهية بشأن أموال المرافق العامة الاقتصادية

لقد تعددت الاتجاهات الفقهية وتباينت بشأن ملكية أموال المرافق العامة الاقتصادية التي تدار بطريقة الاستغلال المباشر، أو بطريقة المؤسسات والهيئات العامة، كالتالي:

الفرع الأول الطبيعة القانونية لأموال الهيئات والمؤسسات العامة

لقد ذهب رأي في الفقه إلى القول بالاستقلال المالي للهيئات والمؤسسات العامة، على أساس وجود ميزانية مستقلة لها عن ميزانية الدولة (٦)، وذهب رأي آخر إلى أن استقلال المؤسسة العامة التي يتألف الجزء الأكبر من

١ د. أحمد حمد الفارسي، د. خليفة الحميدة، القانون الإداري، جامعة الكويت، كلية الحقوق، ٢٠١٥، ص ٢١.

٢ د. ثروت بدوي، النظرية العامة للعقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٦، ص ٦٢.

٣ د. عزيزة الشريف، د. يسري العصار، القانون الإداري، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ١٩٩٩، الطبعة الأولى، ص ٩٧ وما بعدها.

4 RIVRO. Le Regime des Nationalisations. J. C. P. 1948. P. 700.

5 Auby (J.M.), et DUCOS – ADER. Grands Services Publics et entreprises nationales. 1975. T. 1. P. 123.

6 Maestre (J.C.), Le Controle des budgets des etablisemnts d'enseignement. A.J.. 1987. P. 643.

ميزانيتها من الإعلانات التي تقدمها لها السلطة المركزية هو استقلال ظاهري (١).

فهذا الاستقلال يكون قد تحقق في نطاقه القانوني فقط وليس الفعلي، ويلزم لتحقيق الاستقلال للهيئات والمؤسسات العامة أن تكون لها حسابات خاصة بها تختلف عن حسابات الدولة المرتبطة بها عضوياً، وأن تكون لها القدرة على تحقيق الإيرادات الذاتية لها، وأيضاً ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة للدولة، ويعد استثناء من مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة.

ولا يوجد نظام قانوني مالي موحد يحكم جميع الهيئات والمؤسسات العامة على اختلاف أنواعها، فعندما دخلت الدولة إلى الميادين التجارية والصناعية زاد تدخل الدولة هذا شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى قمته حينما باشرت الدولة أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة، وذلك بسيطرتها على وسائل الإنتاج الحيوية عن طريق إخراج مجموعات واسعة من وسائل الإنتاج والمبادلة، ونقلها من النطاق الخاص إلى النطاق العام (التأميم)، أو إنها قامت بإنشاء مشروعات عامة حتى يكون لها الدور القيادي في توجيه اقتصاد الدولة، فظهرت المؤسسات والهيئات العامة (٢). وهنا لابد من التساؤل حول النظام القانوني لأموال المؤسسة العامة، ومن هو المالك للأموال المخصصة للمؤسسات العامة، هل هي الدولة أم المؤسسة العامة ذاتها؟

وإذا كانت أموال المؤسسة العامة تملكها الدولة فهل تدخل في نطاق أموال الدولة العامة أو في نطاق أموالها الخاصة؟ وهل تتمتع تلك الأموال بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها أموال الدولة العامة؟ لذلك نتعرض بإيجاز لكل هذه التساؤلات من خلال الاتجاهات الثلاثة التالية:

الاتجاه الأول: يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن ملكية الأموال المخصصة للمؤسسات العامة هي ملكية مزدوجة للدولة والمؤسسة العامة ومنها المشروعات العامة، وذلك على اعتبار أن هذه الملكية هي نوع جديد، ولذلك يجب التفرقة بين حقين:

الأول: هو حق الانتفاع ويكون للمؤسسة العامة والمشروع العام حيث يخول هذا الحق إدارة الأموال وفقاً لقواعد الإدارة الاقتصادية، شريطة عدم الانتقال من القيمة الإجمالية لرأس المال الذي خصصته لها الدولة عند إنشاءها أو آلت إليها عن طريق التأميم (٣).

أما الحق الثاني: فهو ملكية الرقبة وهذا يكون للدولة، وبالتالي يجب استبعاد أي نوع من أنواع التملك الخاص لأموال المشروع، ولها الحق في الرقابة على المشروع، بل وهي التي تقرر مصيره (٤).

الاتجاه الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المؤسسات العامة هي المالكة لتلك الأموال ملكية حقيقية وتامة فهي ملكية كاملة وليست مجزأة (٥)، وبالتالي تبقى للمؤسسة العامة ملكية هذه الأموال حتى ولو آلت هذه المؤسسة للدولة وفقاً لقوانين التأميم.

ولا يعير أنصار هذا الاتجاه أي إهتمام للنصوص التشريعية التي نقلت بعمليات التأميم المتعاقبة لكثير من المشروعات الخاصة ذات الأهمية، ونقلها بذلك إلى ملكية الدولة نظراً لأن هذه النصوص تخفي وراءها بواغث

١ د. سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٨، ص ١١٣.
٢ د. محمود أحمد سليمان البراشدي، النظام القانوني لأموال المرفق العام في ظل سياسة الخصخصة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ٢٠٠٩، ص ٣١٥.
٣ د. سعد العلوش، المرجع السابق، ص ١٣١ وما بعدها.
٤ د. حمد زيدان نايف محمد العنزي، الحماية الجنائية للمرافق والأموال العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ١٩٩٥، ص ٣٧.
٥ د. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٢، ص ٦٣٧.

سياسية لا مجال للتمسك بها في نطاق القانون (١).

كما أن المؤسسات العامة لها قدرة على تملك جميع أنواع الأموال أياً كانت طبيعتها وعلى إدارتها التصرف فيها كأى شخص عادي، والقول بغير ذلك يجال في الواقع والمنطق بالإضافة إلى أن المرافق العامة الإدارية تملك أموالها، وهذا يعني أن المؤسسات العامة التي آلت إليها الأموال بفعل التأميم تتشابه مع طبيعتها السابقة في ملكية الأموال فكلاهما مالك لها وله حقوق ملكية عليها (٢).

الاتجاه الثالث: ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الدولة هي المالكة لأموال المؤسسات العامة والمشروعات العامة، ولا يمكن اعتبار المؤسسات والهيئات العامة مالكة لتلك الأموال، وإنما لها حق الإنتفاع والإدارة فقط، ولا يعني نقل هذه الإدارة للمؤسسة العامة أن يكون له تأثير على طبيعة هذه الأموال، حيث تبقى خاضعة لذات القواعد القانونية التي تخضع لها أموال الدولة العامة.

ويدلل أصحاب هذا الاتجاه بأن المشرع الفرنسي يعتبر المؤسسات العامة الإدارية - وهي شخص معنوي عام - تنشأ نتيجة فرز ذمة مالية عامة وتخصيصها على أحد المرافق العامة، بحيث لا يترتب على هذا التخصيص مطلقاً أن تكون المؤسسة العامة هي المالكة للأموال المخصصة لها.

ومعنى هذا أن الدولة تظل هي المالكة ولها الكلمة الأخيرة في مصير تلك الأموال، بل وفي مصير بقاء المؤسسة ذاتها وهذا الأمر لا يستقيم إلا إذا كانت الدولة هي المالكة لأموال المؤسسات العامة، والمرافق العامة تخضع للدولة وتمارس عليها حقوق المالك وهيمنتها عليها (٣).

ومن ناحية أخرى يذهب البعض (٤) إلى اعتبار أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة، وذلك على اعتبار أن مفهوم المنفعة العامة قد توسع بسبب تدخل الدولة في مجالات عديدة، وأبرزها المجال الاقتصادي.

حيث قامت الدولة بإنشاء مشروعات اقتصادية ضخمة لأجل تحقيق المنفعة العامة، وهذه المشروعات تتفق مع الهدف الذي تحققه أموال الدولة العامة، ولا يتصور الابتعاد بأموال هذه المؤسسات عن الحماية القانونية التي تقررها القوانين لأموال الدولة العامة وإخضاعها للقواعد العادية مما يضعها بعيدة عن مبادئ الحماية التي أصبحت مستقرة للأموال العامة.

إضافة إلى عدم إخضاع هذه الأموال لقواعد شهر الإفلاس، ووضعها تحت التصفية القضائية، وفي هذا الشأن يقرر الفقه الفرنسي أن قانون (٢٥) يناير ١٩٨٥ بشأن التصفية القضائية لا يطبق على المؤسسات العامة (٥).

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسي على عدم جواز ممارسة طرق التنفيذ المقررة في القانون الخاص تجاه جميع الأشخاص العامة سواء كانت إدارية أو صناعية أو تجارية (٦).

وحتى في مواجهة المشروعات العامة التي لها وصف الشركات الخاصة فإن القضاء الفرنسي يستبعد تطبيق قواعد التصفية القضائية، نظراً لكون المشرع لم يخضع هذه الشركات لقواعد القانون التجاري إلا بشرط إتفاقها مع موضوع المرفق العام، والقانون الخاص بالتصفية القضائية يتعارض في سياسته مع هذا الهدف.

١. د. محمود أحمد سليمان البراشدي، المرجع السابق، ص ٢١٦ وما بعدها.

٢. د. سعد العلوش، المرجع السابق، ص ١٣٠.

٣. د. فتحي عبد الصبور، المرجع السابق، ص ٦٢٢.

٤. د. سعد العلوش، المرجع السابق، ص ١٣٥.

5. DE LAUBADERE (A.) VENEZIA (J.C.), GAUDMET (Y.), Traite de droit administratif. T. 1. LGDJ, 1996. P. 418.

6. Cass. Civ., 1er Dec. 1987, Bull. N. 1. 348, P. 249, J.C.P., 1981, II. 21113, note (B.) Nicod.

ولذلك رفضت محكمة النقض الفرنسية تطبيق قانون (٢٥) يناير ١٩٨٥ عند نظر قضية شركة الخطوط الفرنسية إيرفرانس (١)، ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق قواعد الإفلاس على المشروع الخاص الذي يدير مرفقاً عاماً كما هو الشأن بالنسبة للملتزم (٢).

ونخلص إلى أن عدم تطبيق قواعد التصفية القضائية على المؤسسات العامة التي تقوم بإدارة مرفق من مرافق الدولة يعد من المبادئ القانونية العامة، والذي يتقرر حتى بدون نص خاص، ولذلك يكون منطقياً أن يقرر المشرع هذا المبدأ دون أن يكون هناك عوار دستوري.

وفي هذا قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية «بعدم مخالفة المادة (٧٦) من القانون رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام للدستور، فيما تضمنته من عدم جواز شهر إفلاس شركات القطاع العام» (٣).

1 Cass. Soci., 17 Avril 1991. Groupement des Assedic DE La region Parisienne C./ Cie Air France. J.C.P., 1991, P. 3.

٢ د. محمد محمد عبداللطيف، التطورات المعاصرة للمرافق العامة الإقتصادية، مجلة النشر العلمي، جامعة الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩، ص ١٨٩، هامش ١٣.

٣ الدعوى رقم (٤) لسنة (٢) ق. دستورية جلسة ١٩٧٢/٧/١، المجموعة الدستورية، ج ١.

الفرع الثاني

الطبيعة القانونية للأموال المخصصة للمرافق العامة الاقتصادية

إن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي لإشباع الحاجات العامة، ترتب عليه ظهور المرافق العامة الاقتصادية للقيام بهذا الدور، مما أدى إلى إثارة التساؤل حول طبيعة أموال تلك المرافق، وما إذا كانت أموال عامة أم أموال خاصة. ولذلك نجد أن الآراء انقسمت في فرنسا بشأنها ما بين كونها أموالاً عامة وتتمتع بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها أموال الإدارة، وهناك من يتطلب الرجوع للنصوص القانونية المتعلقة بكل مرفق حتى يمكننا تحديد طبيعتها، وأخيراً تطلب فريق ثالث شروطاً محددة لا بد من توافرها لإضفاء صفة المال العام على الأموال المخصصة للمرافق العامة الاقتصادية، وستناول هذه الآراء على النحو التالي:

الرأي الأول: يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن أموال المرافق العامة الاقتصادية تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له أموال المرافق العامة الإدارية وهو النظام القانوني لأموال الدولة العامة. وبالتالي فإن أموال المرافق العامة الاقتصادية تعد أموالاً عامة، وتتمتع بذات الحماية القانونية التي تتمتع بها أموال الإدارة (١).

الرأي الثاني: يذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه لا بد لكي نعرف الطبيعة القانونية لأموال المرافق العامة الاقتصادية من الرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بكل مرفق حتى يمكننا تحديد ما يعد من أمواله أموالاً عامة أو أموالاً خاصة، فإذا ما أفادت هذه النصوص بخضوع أموال المرفق من حيث إدارتها لنظام القانون الخاص فهي أموال خاصة، أما إذا أخضعت هذه الأموال لنظام القانون العام فإنها تعتبر من الأموال العامة (٢).

الرأي الثالث: تطلب أنصار هذا الرأي ثلاثة شروط حتى تكون الأموال المخصصة للمرافق العامة الاقتصادية أموالاً عامة، وهي: أن تكون هذه الأموال مخصصة لتسيير هذه المرافق، وأن تكون هذه الأموال مملوكة لشخص من أشخاص القانون العام، وأخيراً أن تدار هذه المرافق عن طريق الإدارة المباشرة أو المؤسسة أو الهيئة العامة، ويفرق أصحاب هذا الرأي بين أمرين:

أولاً: أن تكون الأموال المخصصة لتسيير المرافق الاقتصادية مملوكة أصلاً للشخص العام المانح للالتزام، فهنا يعتبرون جميع هذه الأموال من الأموال العامة، ومن ثم تتمتع بالحماية التي تقررها القوانين للمال العام.

ثانياً: أن تكون هذه الأموال مملوكة أصلاً للملتزم (وهو هنا شخص من أشخاص القانون الخاص) فتعد هذه الأموال من الأموال الخاصة على الرغم من تخصيصها لتسيير المرافق العامة الاقتصادية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري أسبغ على أموال المرافق العامة الاقتصادية المملوكة للملتزم (شخص خاص) ذات الحماية المقررة للأموال العامة، ومن ذلك المادة (٨ مكرر) من قانون التزام المرافق العامة رقم (١٢٩) لسنة ١٩٤٧ والمعدل بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٨ «لا يجوز الحجز ولا إتخاذ أي إجراءات أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات الخاصة لإدارة المرافق العامة على اعتبار أن تلك الأموال خصصها الملتزم

١ قام الفقيه الفرنسي (Rolland) بتقسيم أموال المرافق الاقتصادية إلى أموال المرافق العقارية وأموال المرافق المنقولة، وأعتبر أن الأولى لها نفس المركز القانوني الذي تحتله العقارات المخصصة لإدارة المرافق العامة الإدارية حيث يكون لكل منهما صفة المال العام، وتتمتع بالحماية القانونية على حد سواء، أما الثانية فتقسم أيضاً لقسمين، فهناك منقولات مخصصة لتسيير المرفق العام الاقتصادي وتعتبر مالا عاماً، والثانية تعتبر مالا خاصاً ولا يحكمها سوى القانون الخاص كاللبضائع والمنتجات المعدة للبيع، انظر: د. إبراهيم عبدالعزيز شيجا، المال العام في القانون المصري والمقارن، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الجزء الأول، ١٩٧٥، ص ٥٠.

٢ تبني هذا الرأي من الفقه الفرنسي: Aubry et Ducos Ader Jean - Marie

للمزيد حول هذا الرأي أنظر: د. إبراهيم شيجا، المرجع السابق، ص ١٨، هامش (١).

لتسيير وإدارة المرفق العام وذلك ضماناً لدوام سيره بانتظام وإطراد». فالمرشع أقر حماية أموال الملتزم مثلها في ذلك مثل الأموال العامة، بالرغم من أن أموال المرفق العام الاقتصادي الذي يديره يعد مملوكاً له ملكية خاصة (١)، وبالتالي إذا اختل شرط من هذه الشروط بأن كانت أموال المرافق الاقتصادية ليست مخصصة لتسيير هذا المرفق، أو كانت لا تدار عن طريق الإدارة المباشرة، فإن أموالها تعتبر أموالاً خاصة.

وفي الكويت يرى البعض (٢) أن مكن الصعوبة في وصف هذه الأموال بالخاصة فيعتقد البعض بأنها بهذا الوصف ليست أموالاً عامة والحقيقة إن وصف خاصة يقصد به طبيعة ملكية الدولة عليها فهي مملوكة للدولة ملكية خاصة، أي أنها غير مخصصة للنفع العام وإن كانت مملوكة للدولة، وإن كانت هذه الأموال هي مصدر للإيرادات العامة أي للميزانية العامة للدولة.

إن الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة هي المعنية بمصطلح الدومين أصلاً فمنها تتكون الإيرادات الأساسية للدولة لإشباع الحاجات العامة، وفي حقيقة الأمر تعتبر المرافق العامة الاقتصادية مالكة لأموال خاصة في طبيعتها (٣)، فمرفق الكهرباء هو مرفق عام اقتصادي رأت الدولة في الكويت أن تمتلك إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن هذه الملكية لا تغير طبيعة المرفق أو المال فلا تزال الدولة تبيع التيار الكهربائي وتحصل على ثمن عام هو ثمن الكيلو وات من التيار الكهربائي، وهذا المال هو مال خاص للدولة وليس من الدومين العام. ولذلك فالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة تخضع لأحكام القانون الخاص، ومنازعات تلك الأموال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، وإنما للدوائر المدنية والتجارية الحكومية، وتصدر فيها أحكام قضائية خاصة مدنية وتجارية.

المطلب الثاني المعيار المميز لأموال المرافق العامة الاقتصادية في التشريعين الكويتي والمصري

لقد تناولت فيما سبق - الخلاف الفقهي - حول طبيعة أموال المرافق العامة الاقتصادية، وأن المتفق عليه خضوع هذه الأموال لقواعد القانون الخاص، إلا أن ملكية الدولة لأموال المرفق يجعل من الصعب أن نفرق بين المال العام والخاص وترجع أهمية ذلك أن المال العام يخضع لذات القواعد التي تطبق على الأموال الخاصة. فلا بد من معيار محدد لمعرفة هذه الأموال حتى تكفل أداءها للغرض الذي خصصت لأجله بوصفها أموالاً مملوكة

١. قضت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الجزئية بأن «المتفق عليه أن المرفق العام إنما يقوم بأداء الخدمات لجمهور المنتفعين تحقيقاً للمصلحة العامة، ومن ثم يجب إحاطته بكافة الضمانات التي تمكنه من أدائها بصورة مضطردة ومنظمة لجمهور المنتفعين تحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً لمبدأ عدم تعطيل سير المرافق العامة، ومن بين هذه الضمانات هو عدم جواز التنفيذ على الأموال اللازمة لسيرها، فإذا كانت هذه الضمانات متوافرة بطبيعة الأشياء بالنسبة للمرافق التي تديرها الدولة والأشخاص الاعتبارية بطريق مباشر باعتبار أن أموالها ضمن أموال عامة بطبيعتها لا يجوز توقيع الحجز عليها، فإنه من المتفق عليه أنه بالنسبة للمرافق التي تدار بطريق غير مباشر أنه بالرغم من أن أموالها تظل ملكاً خاصاً للملتزم الأصلي وتدخل في الضمان العام لدائنيه، إلا أن هذه الأموال يجب إحاطتها بضمان عدم جواز توقيع الحجز عليها إلا في الحدود التي لا يعارضها سير المرفق ذاته، لأن القاعدة في حالة تعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تقضي بتغليب المصلحة الأولى دون الثانية، ومن ثم فلا يجوز لدائني الملتزم توقيع الحجز على الإيراد إلا في الحدود التي لا تمنع من سير المرفق ذاته والاستمرار في أداء خدماته للجمهور، كما أنه لا يجوز من باب أولى توقيع الحجز على ذات الأموال موضوع المرفق»، حكم قاضي الأمور المستعجلة، بمحكمة القاهرة، الصادر بتاريخ (١٠) نوفمبر ١٩٥٤.

٢. د. إبراهيم محمد الحمود، المالية العامة للدولة، دراسة تأصيلية في فقه المالية العامة والقوانين المالية مع الإشارة المالية دولة الكويت، جامعة الكويت، كلية الحقوق، ٢٠١٢، الطبعة الأولى، ص ٥٣٨.

٣. د. إبراهيم محمد الحمود، المرجع السابق، ص ٥٣٩.

للدولة وإن لم تدرج في نطاق الأموال العامة، وبناء على ما تقدم سوف نتناول المعيار المميز لأموال المرافق العامة الاقتصادية في التشريعين الكويتي والمصري كالتالي:

الفرع الأول

المعيار المميز لأموال المرافق العامة الاقتصادية في التشريع الكويتي

أكدت المادة (١٧) من الدستور الكويتي على أن «لأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» وكذلك نصت المادة (١٣٥) على أن «يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها». ثم تناول في المادة (٢١) الثروات الطبيعية كالتالي «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». وبصدور القانون المدني الكويتي رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠، يلاحظ أنه لم يعرف المال العام صراحة إلا أنه نص في المادة (٢٣) منه على أنه «كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص، كما لا يجوز وضع يد الغير عليه، وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون». ووفقاً لما سبق يتبين لنا أن المشرع الكويتي أخذ في تحديد الأشياء العامة بمعيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو نفس المعيار الذي أخذ به المشرع المصري المادة (٨٧) مدني وتقابلها المادة (٢٣) من التقنين الكويتي، ويشترط معيار التخصيص للمنفعة العامة في المال شرطان: الشرط الأول: أن يكون هذا المال خاصاً بالدولة أو بأحد أشخاص القانون العام الأخرى، أما إذا كان المملوكاً للأفراد فإنه لا يمكن أن يكون مالاً عاماً إلا إذا انتقل إلى شخص من أشخاص القانون العام بإحدى الطرق المشروعة كنقل الملكية بالتراضي، أو قهراً بإتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة التي نص عليها القانون. الشرط الثاني: التخصيص للمنفعة العامة، ويتطلب التشريع الكويتي أن يكون التخصيص بنص تشريعي أو بقرار إداري صادر من رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أية جهة إدارية يخولها القانون ذلك أو يكون بالفعل كأن تأخذ الدولة مالاً من أموالها وتخصصه للمنفعة العامة.

وتهدف الدولة من إنشاء المشروعات الاقتصادية تحقيق التنمية في الدولة ولتوفير الخدمات للأفراد أو لتحقيق غايات سياسية كإنشاء مؤسسة الطيران (مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية) ومعرفة نوع المال تعد من المسائل الهامة، لاسيما بعد توسع مفاهيم الخصخصة وعودة هيمنة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي في الدول المختلفة (١).

الفرع الثاني

المعيار المميز لأموال المرافق العامة الاقتصادية في التشريع المصري

وضع التقنين المدني المصري معياراً عاماً يطبق على كافة الأموال سواء التي يعتبرها أموالاً عامة أو خاصة، حيث نص في المادة (٨٧) على أن «تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة،

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو (مرسوم) أو قرار من الوزير المختص (١) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

أما المادة (٨٨) فقد نصت على أن «تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو (مرسوم) أو قرار من الوزير المختص أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة».

ومن هذه النصوص يتضح لنا أن المشرع المصري أبقى على المعيار الذي أخذ به التشريع القديم، في تحديد صفة المال العام وهو (تخصيصه لمنفعة عامة) وهذا يتفق مع آراء الفقه الفرنسي.

ويذهب البعض (٢) إلى أن المعيار الذي تبناه المشرع المصري بالغ الإتساع نظراً لأنه يعتبر مالياً عاماً الأموال التي تكون مخصصة لمنفعة عامة ولذا يتطلب القانون المدني المصري توافر شرطين لكي يعتبر المال عاماً:

الشرط الأول: أن يكون هذا المال خاصاً بأحد أشخاص القانون العام:

ويستفاد هذا الشرط من نص عبارات المادة (٧٨) من القانون المدني حيث يعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.

الشرط الثاني: أن يخص هذا المال لمنفعة عامة:

وهذا التخصيص إما أن يكون باستعمال الجمهور للمال العام مباشرة كالطرق وطرق الملاحة، وإما أن يكون باستعمال الجمهور للمال العام عن طريق مرفق عام كالسكك الحديدية والتلغراف والتليفون، ولهذا فإن الأموال العامة تشمل الأموال المنقولة والعقارية.

ويعترف الفقه المصري (٣) للأشخاص العامة المرفقية بحق تملك الأموال العامة التي تتبعها، وهذا ما أشارت إليه أحكام القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٦٣ بشأن إنشاء الهيئة أو المؤسسة حيث يبين الأموال التي تدخل في ذمتها المالية وكذلك الأموال الخاضعة لإدارتها وتحدد صفتها العامة أو الخاصة (٤).

ووفقاً لما تقدم فإن معرفة عناصر الذمة المالية العامة التابعة للأشخاص المرفقية يتطلب الرجوع إلى القوانين والقرارات المنشأة للهيئات العامة والمحددة لتلك العناصر.

وبالنسبة للمرافق العامة الاقتصادية المحلية، فإن قانون الإدارة المحلية المصري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ قد أشار إلى أن للمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى لكل منهما الشخصية المعنوية.

وحدد القانون الموارد المالية المخصصة لهذه المجالس وتضم بصفة عامة كافة موارد المرافق العامة المحلية من كهرباء ومياه وغيرها، وتدخل الأموال العامة المخصصة لهذه المرافق في ملكية الأشخاص المحلية التابعة لها (٥).

١ عبارة «أو إقرار من الوزير المختص» أضيفت بالقانون رقم (٣٢١) لسنة ١٩٥٤.

٢ د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الخط العربي، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٥٥٠.

٣ د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٢، ص ٥٣٣.

٤ ومن ذلك القانون (١٤٦) لسنة ١٩٥٧ بإنشاء الهيئة العامة لقناة السويس والقانون رقم (١٥٢) لسنة ١٩٨٠ المنشئ للهيئة العامة للسكك الحديدية، والقانون رقم (١٥٢) لسنة ١٩٨٠ المنشئ للهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

٥ د. فؤاد العطار، المرجع السابق، ص ٥٣٩.

المبحث الثاني القواعد الخاضعة لها أموال المرافق العامة الاقتصادية

لا شك أنه في حالة إكتساب المرافق العامة الاقتصادية لأموالها فإنها تخضع لعدة قواعد تجعلها قادرة على التطوير وملائمة في ذات الوقت للطبيعة الاقتصادية لهذه المرافق، ولما كانت هذه الأموال لا تأتي من فراغ وإنما لابد لها من مصدر تأتي من خلاله ليقوم المرفق على إشباع الحاجات العامة وفقاً لمتطلبات المجتمع. وعليه فإنني سوف أتناول القواعد العامة التي تخضع لها أموال المرافق العامة الاقتصادية، ومصادر هذه الأموال، ثم أتطرق إلى التطور الخاص بالنظام القانوني لأموال المشروعات العامة، وذلك كالتالي:

المطلب الأول القواعد العامة لأموال المشروعات العامة

إن أموال المشروعات العامة تأتي من مصدرين مختلفين، أما المصدر الأول فهو أن تقوم الدولة بنقل الأموال إلى المشروع، وقد يتم هذا النقل بطريق الاتفاق، خصوصاً من خلال عقد الالتزام، فقد تنازلت الدولة في فرنسا لكل من شركة السكك الحديدية (SNCF) وشركة الكهرباء الفرنسية (EDF) عن الجزء الأكبر والأهم من الأموال، مثل: طرق السكك الحديدية، ومنشآت إنتاج الكهرباء (١). هذا ويمكن أن تقدم الدولة إلى المشروعات العامة أموالاً لزيادة رأس المال، وأخيراً قد تقوم الدولة بإعادة تخصيص بعض الأموال إلى المشروعات بعد أن كانت تشكل جزءاً من أموال وزارة أو شخص عام آخر، مثال ذلك أيلولة مقار مكاتب البريد إلى هيئة البريد، والتي كانت تستأجرها من هيئة السكك الحديدية (٢). وأما المصدر الثاني فهو أن يقوم المشروع باكتساب الأموال، وهذا الاكتساب يمكن أن يتم وفقاً للقواعد العامة مثل الشراء، وقد يتم وفقاً لإجراءات أخرى مثل إجراءات نزع الملكية. وهنا لابد من التساؤل عن تحديد من يملك أموال المشروعات العامة، هل تملكها الدولة أم المشروع نفسه؟ وقد ساهمت بعض الاعتبارات في غموض الإجابة عن هذا التساؤل. فمن ناحية فإن الشائع أن المشروع العام تملكه الدولة، وبالتالي فإن أموال هذه المشروعات قد تكون مملوكة للدولة، ومع ذلك، فإن هذه الفكرة تتعارض مع الاعتراف للمشروع العام بالشخصية القانونية والاستقلال الذي يعترف به القانون لهذا المشروع، غير أن علاقة الدولة بالمشروع العام غير منقطعة، لأنها تملك في مواجهته نوعاً من الهيمنة أو الرقابة.

ومن ناحية أخرى فقد أحدثت تشريعات التأمين قدراً كبيراً من الغموض حول هذا الموضوع، لأنها تنص على أن رأس مال المشروع المؤمم يكون للأمة (٣)، أو لأنها تحدد صراحة بأن تؤول ملكية الشركات المؤممة إلى الدولة

١ () د. عزت فوزي حنا، المرفق العام الاقتصادي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ١٩٩٢، ص ٣٥٨ وما بعدها.

كذلك انظر: د. محمود أحمد سليمان البراشدي، المرجع السابق، ص ٥٨٣ وما بعدها.

٢ () ج.م.ع (٧) من أغسطس ١٩٩٦، الفتوى رقم ٧١٧، ملف رقم ٢٣٧٢/٢٢، المجموعة، السنة ٥٠، ص ٦٤٢.

٣ () المادة (١٦) من قانون (١٨) أبريل ١٩٤٦ بشأن تأمين شركات الكهرباء والغاز، والمادة (١٨) من قانون (١٧) مايو ١٩٤٦ بشأن تأمين شركات الفحم واستغلال زيوت الطاقة في فرنسا.

(١).

ومع ذلك فالفقه والقضاء لا يتوقفان عند ظاهر هذه النصوص، ومن المسلم به أن المشروعات العامة المؤممة تملك الأموال التي آلت إليها بالتأميم، وهذا ما أكدته مجلس الدولة (٢)، ومحكمة النقض (٣) في فرنسا.

وفي مصر أيضاً رأي مجلس الدولة أنه على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم (١١٧) لسنة ١٩٦١ قد نصت على «أيلولة ملكية الشركات والمنشآت المؤممة والمبينة بالجدول المرفق بالقانون إلى الدولة»، فإن هذه الشركات تعتبر هي المالكة لجميع أموالها بوصفها شخصاً معنوياً ذا ذمة مالية مستقلة تماماً عن ذمة الهيئة العامة المالكة للأسهم، وأنه لا يؤثر في ذلك أن تكون الشركة بأكملها مملوكة لشخص معنوي آخر هو الدولة أو المؤسسة العامة، إذ أن اختلاف الشخصيتين يقتضي حتماً أن تستقل كل منهما بملكية أموالها (٤).

وهذا لا يعني أن المشروعات العامة تملك جميع الأموال المخصصة لها، فقد تعهد بعض النظم إلى المشروعات العامة ببعض الحقوق على أموال دون أن تجعلها مالكة لها، ويتحقق هذا الفرض في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: فهي أن تؤول الأموال إلى المشروع وفقاً لعقد الالتزام، ومن المسلم به أن جزء من أموال هذه المشروعات يجب إعادته إلى الدولة وهذه الأموال تعتبر ملكية الدولة، وتثبت لها هذه الملكية ليس في نهاية مدة الالتزام، وإنما قبل ذلك أثناء فترة تنفيذ الالتزام (٥).

الحالة الثانية: فهي أن تنقل أموال إلى المشروع الذي لا يمارس عليها إلا سلطات الإدارة على أن يتحمل بالتزامات المالك، من ذلك أن قانون (٣٠) ديسمبر ١٩٨٢ في فرنسا قد قرر نقل أموال عقارية إلى مؤسسة السكك الحديدية (SNCF)، وهي مملوكة للدولة، بينما تمارس عليها المؤسسة ليس حق الملكية وإنما حقوق والتزامات من طبيعة أخرى.

وبطبيعة الحال، فإن الأموال التي يكتسبها المشروع بعد إنشاءه، تظل مملوكة له، وقد أكد القضاء على حق المشروعات العامة في ملكية هذه الأموال، ومنها على سبيل المثال: محطات الطاقة الحرارية وغيرها من المنشآت التي تنشأها مؤسسة الكهرباء والغاز (٦).

وتكرس بعض القوانين في مصر صراحة على اعتبار أموال الهيئات الاقتصادية أموالاً عامة (٧)، ولا تعتبر أموال الهيئات العامة الصناعية والتجارية أموالاً خاصة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً بذلك، ومن ذلك المادة رقم (١٠) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس تنص على «اعتبار أموال الهيئة أموالاً خاصة».

وتطبق على أموال المؤسسات أو الهيئات العامة الصناعية والتجارية المبادئ الخاصة بالأموال العامة التي يأتي في مقدمتها مبدأ عدم جواز التصرف، ويتم تفسير هذا المبدأ ليس فقط على أنه يحظر أي تصرف ناقل للملكية، وإنما أيضاً أي عمل أو إجراء يمكن أن يؤدي بصفة احتمالية إلى نقل الملكية.

١ المادة الأولى من القرار بقانون رقم (٧٢) لسنة ١٩٦٣ في مصر.

2 CE. Ass. Ler sep. 1950. Rec., P. 595; D. 1952. note L'Huillier. S. 1951. 3. 61. note Boulouis; CE. 7 nov. 1962. EDFC / Consorts Jacquet. AJDA. 1963. II. 184. note (A.) de Laubadere.

3 Cass. Civ.. 3 mai 1988. consorts Renault C./ EDF. CJEG. 1988. P. 50. rapp. Sargos.

٤ ج.م.ع. ٢٢ يونيو ١٩٦٣، الفتوى رقم ٩٨١، ملف ٦٥/١/٤٧ المجموعة، ١ لسنة ١، ص ٣٣٩.

5 CE. 23 oct. 1963. SNCF. Rec., P. 497; AJDA. 1964. P. 321. note Laporte: RDP. 1963. P. 1191. Concl. Braibant; 4 fev. 1970. Minsitire de bequipleminet C./SNCF. Rec., P. 84. AJDA. 1970. II. P. 421. note Duffau.

6 CE. 7 nov. 1962. EDF C. Faivre. AJDA. 1963. II. P. 184. note A. de Laubadere.

٧ انظر المادة (٧) من القانون رقم (١٥٢) لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادة (٥) من القانون رقم (١٩) لسنة ١٩٨٢ بإنشاء الهيئة القومية للبريد، والمادة (٤) من القانون رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للإنفاق.

وعلى ذلك فإن مبدأ عدم جواز التصرف يعني نتيجتين: عدم جواز الحجز على الأموال العامة، وعدم ترتيب أي حق عيني عليها، غير أن التطور القضائي والتشريعي قد اتجه مؤخراً إلى الخروج على مبدأ عدم جواز التصرف في أموال المؤسسات أو الهيئات العامة الصناعية والتجارية.

المطلب الثاني تطور النظام القانوني لأموال المشروعات العامة

لقد حدثت تطورات خاصة بالنظام القانوني لأموال المشروعات العامة، فلم يعد مبدأ عدم جواز التصرف في هذه الأموال يطبق بصورته الجامدة، وإنما أصبح يحتمل بعض مظاهر الخروج عليه، ومن ذلك (١):

(١) الخروج على مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة:

تؤكد نصوص التقنين المدني الكويتي (مادة ٢٣) والتقنين المدني المصري (مادة ٨٧) على أن الأموال العامة لا يجوز الحجز عليها، كما يقرر تقنين ملكية الأشخاص العامة في فرنسا أن أموال الأشخاص العامة لا يجوز الحجز عليها، وهذه الأموال تشمل الأموال العامة والخاصة على حد سواء.

وهذا المبدأ يطبق أيضاً على المشروعات العامة، إذ لا يوجد ما يسوغ إعفاء المؤسسات العامة الصناعية والتجارية من هذا المبدأ، وحتى ولو كانت تمارس نشاطاتها وفقاً لذات الشروط أو الأوضاع التي تحكمها القواعد العامة، أي قوانين التجارة، وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن عدم جواز الحجز على أموال الأشخاص العامة مبدأ قانوني عام (٢).

ومع ذلك فإن مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة لم يخل من تحفظات للفقه، فقد رأى البعض أن هذا المبدأ لا يحتفظ بقيمته الكاملة إلا إذا كان موضوعه ووظيفة حماية استمرار المرفق العام وعدم تهديد إدارته (٣)، ويستدل بعض الفقه بموقف بعض التشريعات الأوروبية التي تقتصر مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال المخصصة فقط للمرفق (٤).

وقد حدث تطور ملحوظ في القضاء، فقد رأى مجلس الدولة الفرنسي أنه يجوز للدائن - إذا كان لديه سند تنفيذي يثبت له ديناً نقدياً مستحقاً - أن يحجز ما للمدين لدى الغير Saisie - arret، مثل دائتي متعاقدي الشخص العام، ما لم يكن هذا الحجز يتضمن تهديداً لاستمرار المرفق العام (٥).

كما سبق أن قضت محكمة استئناف باريس في (١١) من يوليو بسلامة حجز ما للمدين لدى مؤسسة السكك الحديدية، خصوصاً أنه بالنظر إلى قيمة الحجز، فإن الحجز ليس من طبيعته أن يتضمن إخلالاً بالسير المنتظم والمستمر للمرفق العام (٦).

وأخيراً فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه إذا لم تقم وحدة إقليمية بتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضي به بإلزامها بدفع مبلغ من المال، فإنه يجوز للمحافظ أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الحكم، وله أن يلجأ إلى بيع أموال هذه الوحدة مادام أن هذه الأموال ليست ضرورية لحسن سير المرافق العامة التي تتحمل مسئوليتها، وهذا القضاء يشكل خروجاً جزئياً على مبدأ عدم جواز الحجز على أموال الأشخاص العامة. (٢) إنشاء حقوق إرتفاق للغير على الأموال العامة:

١ د. محمد محمد عبد اللطيف، القانون العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ٢٠١٠، الطبعة الأولى، ص ٥٩٨ وما بعدها.

2 Bureau. De recherché geologiques et minieres. RFDA. 1988. P. 771.

3 Maugue (Ch.) et Bachelier (G.). Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques. 2006. P. 1085.

4 Blanc (F.). L'insaisissabilité des établissements publics industriels et commerciaux. éléments pour une évolution. RDP. 2009. P. 1553 et s.

5 CE. avis. 30 janv. 1992. EDCE. 1992. P. 401.

6 Cité in J. kernionon. Droit public économique montchrestien. 1999. P. 76.

كان الرأي السائد فقهاً هو حظر الارتفاقات على الأموال العامة، ويشمل هذا الحظر ليس فقط الارتفاقات القانونية، مثل حق المرور، وحق المثل، وإنما أيضاً الارتفاقات التي تكون بفعل الإنسان، والارتفاقات الناشئة عن التقادم المكسب (١).

ويقرر القضاء بوضوح أنه لا يجوز إنشاء أي إرتفاق على الأموال العامة، ولا يجيز هذه الارتفاقات إلا إذا كان قد تم تكوينها قبل إلحاق المال محل الإرتفاق بالأموال العامة، وبشرط ألا يكون الإرتفاق متعارضاً مع الغاية التي تم تخصيص المال من أجلها (٢).

غير أن التطور التشريعي قد إتجه مؤخراً إلى الاعتراف بإمكانية تكوين إرتفاقات لاحقة على إلحاق المال بالأموال العامة، فقد أجاز التقنين العام ملكية الأشخاص العامة في فرنسا تكوين إرتفاقات إتفاقية على أموال الأشخاص العامة التي تشكل جزءاً من الأملاك العامة، كلما كان وجودها لا يتعارض مع تخصص هذه الأموال (٣). وقد تكون هذه الارتفاقات لمصلحة الأشخاص العامة أو الأشخاص الخاصة، وقد رحب الفقه بهذا الحكم الجديد الذي يهدف إلى إنشاء علاقات جوار حقيقية وأمنة ومستقرة بين الأموال العامة وأموال الأشخاص الخاصة (٤). (٣) الإعتراف بإنشاء حق عيني لشاغلي الأموال العامة:

إن الرأي المسلم به تقليدياً هو أن مبدأ عدم جواز التصرف في المال العام يتضمن بالضرورة حظر تكوين حقوق عينية على هذه الأموال، وذلك نظراً لأنه ليس للأشخاص العامة أن تتجرد من ملكيتها العامة، إن حظر تكوين الحقوق العينية على الأموال العامة نتيجة طبيعية لمبدأ عدم جواز التصرف، والقانون وحده هو الذي يجوز له أن يستبعده.

وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا التحليل حينما أكد أنه مما يتعارض مع مبادئ الأموال العامة شروط الإنفاقيات التي تتضمن الإعتراف بحقوق عينية على هذه الأموال من خلال عقد إيجار الحكر (٥). غير أن بعض (٦) الفقه قد نادى بضرورة إعادة النظر حول هذا الموضوع، وذلك بالتساؤل حول حقيقة وأهمية ووظيفة مبدأ عدم جواز التصرف في مواجهة الحقوق العينية على الأموال العامة فوظيفة المبدأ هي حماية تخصيص المال العام وضمان هيمنة الشخص العام المالك على المال بهدف خدمة هذا التخصيص، وأنه في هذه الحدود فقط يجب أن يقتصر نطاق هذا المبدأ، فكرة المبدأ هي فكرة وظيفة بالنظر فقط إلى نتائجها، أي بالنظر إلى التخصيص للمنفعة العامة، ومن ثم إذا كان الإعتراف بحقوق عينية من طبيعة حق الملكية للشاغلين للمال العام لا يتعارض مع التخصيص، فإنه يكمل حق الملكية، ويؤدي إلى تعظيم قيمة المال العام، ولا يكون هناك مسوغ لرفض إقرار هذه الحقوق العينية (٧).

وقد نظم تقنين ملكية الأشخاص العامة في فرنسا الإعتراف لشاغلي المال العام بحق عيني، بعد أن كان المشرع الفرنسي قد قرره لأول مرة بقانون (٢٥) من يوليو ١٩٩٤ أن يكون لصاحب التصريح بشغل المال العام بصفة مؤقتة

1 Chapus (R.). Droit Administrative Général. T. II. ed., 1997. P. 512.

2 CE. 29 nov. 1967. Gue. Rec., P. 453.

3 Art. 2122-4 du Code general de la propriete des personnes publiques 2006.

4 Maugue (Ch.) et Bachelier (G.). Genèse et presentation du code general. op. cit., P. 1082.

5 CE. 6 mai 1985. Association Eurolat et Credit foncier de France. RFDA. 1986. P. 21. Concl. B. Genevois.

٦ ومن المعلوم أن إيجار الحكر في القانون الفرنسي هو عقد إيجار يتم إبرامه لمدة لا تقل عن ١٨ عاماً ولا تزيد عن ٩٩ عاماً، ولا يرد إلا على العقارات، وبموجبه يتمتع المستأجر بحق عيني بمائل حق المالك، فله أن يقوم برهن العقار أو أن يؤجره، وإذا قام المستأجر بتنفيذ ميان أو تحسينات، فإن المالك يستفيد منها في نهاية مدة الإيجار دون مقابل، ويقوم المستأجر بدفع مقابل مالي بسيط أو رمزي، انظر: د. محمد محمد عبد اللطيف، القانون العام الإقتصادي، المرجع السابق، ص ٥٩٢، وما بعدها.

7 Gaudment (Y.). Les Droit réels sur le domaine public. AJDA. 2006. P. 1095.

حق عيني على المنشآت والمباني والتجهيزات ذات الطبيعة العقارية التي يقوم بتنفيذها بقصد ممارسة نشاط يسمح به سند الإشغال، وأن الحق يشمل بالضرورة الأراضي التي تقام عليها هذه المنشآت والمباني والتجهيزات (١).

ومن وجهة نظر بعض الفقه (٢) أن هذا النظام يؤدي إلى نتائج مهمة، فهو يؤدي إلى تمكين شاغل الأموال العامة من الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة من أجل تنفيذ استثماراته على هذه الأموال، والاعتراف بهذا الحق العيني لشاغل المال العام يؤدي إلى تحويل شاغله الامتيازات حق الملكية، وهذا أمر يؤدي إلى زيادة قيمة المال. ومن هذه الامتيازات إمكانية التنازل عن بعض عناصر المال في إطار ما يسمح به سند إشغال المال، وإمكانية قبول تأمينات عينية بوصفها دعامة للتمويل، وإمكانية اللجوء إلى الإيجار التمويلي الذي يفترض نقل ملكية الشيء دون التخلي عن الحيازة، والتنازل عن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وإمكانية التوسع في الملكية عن طريق بعض نظم القانون المدني مثل الالتصاق، واستخدام دعاوى الحيازة والاسترداد. ونظراً لأن شغل المال العام لا يكون إلا مؤقتاً وعارضاً، فإن مدة الحق العيني ترتبط بمدة التصريح بشغل المال العام التي يتم تحديدها وفقاً لطبيعة النشاط والمنشآت وأهميتها. ولا يجوز استناداً للحق العيني رهن المنشآت والمباني والتجهيزات إلا لضمان القروض التي يتعاقد عليها شاغل المال العام من أجل تمويل وتنفيذ أو تعديل أو توسيع المنشآت والمباني والتجهيزات ذات الطبيعة العقارية التي تتم على المال المشغول.

ولا يجوز للدائنين العاديين غير الذين تنشأ ديونهم من تنفيذ هذه الأشغال ممارسة أية إجراءات تحفظية أو إجراءات للتنفيذ الجبري، وتنتهي الرهون على الحقوق والمال بنهاية مدة تصاريح الاشغال أياً كانت الظروف والأسباب.

المبحث الثالث

تأثير الخصخصة على رقابة الدولة لأموال المرافق العامة الاقتصادية

إن الخصخصة تعني نقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويطلق على الخصخصة أحياناً تعبير «تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص» (٣). هذا وبعد انتشار ظاهرة الخصخصة في الدول النامية، بدأت هذه الدول في تنفيذ برامج الخصخصة للقطاع العام، وبعد أن تدخل الدولة في مرحلة التنفيذ لابد أن يثور التساؤل التالي: هل تبقى الرقابة المالية على أموال المرافق العامة الاقتصادية باعتباره مال عام أم تتعذر هذه الرقابة المالية، نظراً لأن القطاع العام تحول إلى قطاع خاص، أي تحولت الملكية من أموال عامة إلى أموال خاصة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نعرض لنوعين من الرقابة على النحو التالي:

1 Fournier (A.) et Jacquot (H.). Un nouveau statut pour les occupants du domaine public. AJDA. 1994. P. 759.
Fatome (E.) et Terneyre (Ph.). Chronique de législation. Droites réels sur le domaine public de l'Etat. AJDA. 1995. P. 905.

٢ د. محمد محمد عبد اللطيف، القانون العام الاقتصادي، المرجع السابق، ص ٥٩٣.

٣ د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٩، ص ١١٨ وما بعدها.

المطلب الأول الرقابة البرلمانية على الأموال العامة

تتم هذه الرقابة بواسطة الهيئات التشريعية وينص على هذه الرقابة بالدستور (١) ، وإذا كان التشريع يعد الوظيفة الرئيسية للسلطة التشريعية ، إلا أن هناك وظائف أخرى يعهد بها إليها الدستور كرقابة وفحص نشاط المؤسسات العامة أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصي الحقائق والوقوف على حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية (٢) .

وقد أسند الدستور المصري لعام ٢٠١٢ مهمة تولى الرقابة على الأموال العامة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات في المادة (٢٠٥) (٣) ، وهذا ما أكدته المادة (٢١٩) من الدستور المصري المعدل لعام ٢٠١٤ بأن « يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والأشخاص الاعتبارية العامة ، والجهات الأخرى التي يحددها القانون ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة » .

١ تنص المادة (٨٦) منه دستور ١٩٧١ على أن « يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.... » .
٢ تراجع المادة (١٢٥) من دستور (١١) سبتمبر ١٩٧١ .
٣ تنص المادة (٢٠٥) على « أنه يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والجهات الأخرى التي يحددها القانون » .

الفرع الأول رقابة البرلمان الفرنسي

أخضع الدستور الفرنسي القوانين المالية لنظام خاص يحدده قانون أساسي وتعتبر هذه الإحالة تفويضاً دستورياً للمشرع الأساسي (١) ، وهذا ما أيده المجلس الدستوري في بعض أحكام حيث يرى « أن السلطة التأسيسية قد فوضت القانون الأساسي أن يحدد الطرق التي بمقتضاها يتم تقدير إيرادات الميزانية ونفقاتها، وكذلك موارد أخرى للدولة وأعبائها والتصريح بها بقوانين المالية، ومن ناحية أخرى أن يحدد النصوص غير القابلة للانفصال من هذا التصريح ، وأخيراً فإن استخدام السلطة التأسيسية لاصطلاح التحفظات يتضمن أنها قد منحت اختصاصاً للقانون الأساسي بوضع استثناءات على المبدأ الذي مقتضاه أن قوانين الميزانية هي التي تحدد موارد وأعباء الدولة» (٢).

ولا يفوتنا أن نشير إلى إقرار المجلس الدستوري (٣) لمبدأ التفويض الدستوري للقانون الأساسي الخاص بالقوانين المالية، وأن تلك القواعد القانونية المتميزة عن القوانين العادية والتي تخضع لإجراءات خاصة يرى البعض أن هذا القانون الأساس لقوانين المالية له قيمة دستورية.

الفرع الثاني رقابة مجلس الأمة الكويتي

إن الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة تقوم على إشباع حاجات عامة ، وفي حقيقة الأمر فإن الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي على أعمال الحكومة تعد من أبرز اختصاصاته وأداة لتطور البرلمان ذاته ، ولقد إهتم الدستوري الكويتي بهذه الرقابة ، فجعل الميزانية العامة للدولة تصدر بقانون ، وعهد الاختصاص في إقرار الحساب الختامي للدولة لمجلس الأمة.

ومن ناحية أخرى ألزم الدستور الحكومة بتقديم تقرير مالي للمجلس مرة على الأقل خلال كل دور من أدوات الانعقاد العادية، ولضمان حسن الرقابة المالية للبرلمان الكويتي على أعمال الحكومة ألزمه الدستور بتقديم تقرير سنوي له عن أعماله وملاحظاته.

وبصدور القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة تأكدت هذه الرقابة وذلك بإلحاق الديوان بمجلس الأمة واتضحت معالمه الأساسية في تفعيل الرقابة على الأموال.

وإذا كان مجلس الأمة يراقب الميزانية العامة للدولة وإقرار الحساب الختامي لها ، فإنه يكون مسئولاً أيضاً عن رقابة النفقات والإيرادات العامة ، ومما لا ريب فيه أن أموال المرافق العامة الاقتصادية تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة ، لذلك حرص المشرع على حماية هذه الإيرادات باعتبارها مملوكة للدولة ملكية خاصة. وعملاً على تحقيق هذا الهدف تكفل المشرع الكويتي بتحديد المال محل الحماية وبيان نطاقه في القانون رقم (١)

١ تنص المادة (١٨/٢٤) على أنه "تحدد قوانين المالية إيرادات نفقات الدولة وفقاً للأوضاع وبمراعاة التحفظات الواردة في القانون الأساسي".

2 C.C 25 juillet 2001.448 Dc. RDP.2001.p.1466.note luchsaise.

3 C.C. 9 JUIN 1992.309 DC.REC.P.66.

لسنة ١٩٩٣ (١)، وطبقاً للمادة الثانية منه يعد مالا عاماً الأموال المملوكة أو الخاضعة بقانون لإحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو في خارجها.

وهذه الجهات هي الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ويعتمد في تحديد نسبة رأس المال بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

ووفقاً لذلك أسبغ المشرع الحماية البرلمانية على أموال الدولة بكافة أجزائه ومكوناته ولأجل تفعيل هذه الحماية أنشأت لجنة دائمة في مجلس الأمة « لجنة حماية الأموال العامة » تسري عليها أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عدا الحظر المنصوص عليه في المادة (٤٥) والخاص بالاشتراك في أكثر من لجتين دائمتين لأعضاء مجلس الأمة.

ويقوم ديوان المحاسبة بتلقي إخطارات كتابية من جميع الجهات وتشمل كافة العمليات والتصرفات المتعلقة باستثمار الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها، وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليه من تعديلات.

كذلك لديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من سجلات أو مستندات أو حسابات ويتعين على جميع الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب، ولديوان المحاسبة حق التعقيب على التصرفات وللجهات المعنية حق الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته خلال ميعاد أقصاه (خمسة عشر يوماً) من تاريخ ورودها إليها.

ومن ناحية أخرى على رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من التقرير الشامل لكافة الأموال المستثمرة في الجهات المشرف عليها خلال شهري يناير ويوليو من كل عام ، إضافة إلى ملاحظاته عليه في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التقرير إليه (٢) ، ويرسل إلى لجنة حماية الأموال العامة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة الكويتي.

هذا ويلتزم رئيس ديوان المحاسبة بتسليم رئيس مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ثلاثة شهور بشأن الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة وما يطرأ عليها من تعديلات ، ولمجلس الأمة أن يطلب من ديوان المحاسبة مراجعة كل حساب أو إتخاذ ما يلزم بشأن حماية الدومين الخاص.

الفرع الثالث رقابة البرلمان المصري

يرى البعض (٣) - وبحق - أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالسلطة التشريعية هذه الرقابة ، وذلك لما لها من سلطة وقوة منحت لها من قبل الدستور فهي تمثل الشعب بأسره ، وهذا يجعل كافة الجهات محل

١ القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة الصادر في (٧) فبراير ١٩٩٣ والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، العدد (٩٠)، السنة (٣٩).

٢ لا يفوتنا أن نشير إلى إشمال هذا التقرير على رصد كافة المخالفات والملاحظات خلال العام، انظر: د. إبراهيم محمد الحمود، المرجع السابق، ص ٥٥٤.

٣ د. جيهان حسن خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٩.

رقابة السلطة التشريعية تعمل لتصرفاتها ألف حساب، بل وتحرص على مطابقتها للقانون حتى لا تترك للسلطة التشريعية فرصة سانحة للتنديد بأعمالها ومحاسبتها.

ولا يجوز للسلطة التنفيذية الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة البرلمان (١)، ومن ناحية أخرى يقر البرلمان الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم لا يكفي مجرد عرض الخطة على البرلمان، لأن الإقرار شرط مسبق لتطبيقها، وبالتالي لا يجوز البدء في تنفيذها قبل إقرارها والذي يعد شرطاً سابقاً لتطبيقها (٢).

ويمنح الدستور السلطة التشريعية الاختصاص بوضع القواعد الأساسية الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وبالتالي تعد هذه الموضوعات من الاختصاصات المحجوزة للمشروع، فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنظيمها.

١ المادة (١٢١) من دستور ١٩٧١ والمادة (٥٢) من الدستور الفرنسي تنص على أن «المعاهدات التي تحمل ميزانية الدولة بالتزامات لا يتم إقرارها أو الموافقة عليها إلا بقانون».

٢ د. هشام البدوي، الدور التشريعي للبرلمان في المجال المالي، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، ١٩٩٧، ص ١٢٧.

كذلك انظر: د. محمد محمد عبداللطيف، الحماية الدستورية للمالية العامة، بحث مقدم إلى مؤتمر حماية الأموال العامة، جامعة الزقازيق، فرع بنها، ٢٠٠٤، ص ١٠.

المطلب الثاني الرقابة المالية في ضوء سياسة الخصخصة

تنال الخصخصة من الدور الرقابي للدولة على كافة مرافقها ومؤسساتها حيث ترفع الرقابة عن المشروع الذي تم خصخصته نهائياً إذا تم تسديد ثمن بيعه بالكامل وتم تملكه للقطاع الخاص وانتهاء علاقته بالدولة. ويمكن للدولة أن تتخذ بعض الإجراءات الرقابية والتي تظهر بوضوح من خلال بعض الأجهزة الرقابية المستقلة والمتخصصة ، مثل ديوان المحاسبة في الكويت والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.

الفرع الأول دور ديوان المحاسبة الكويتي

حددت المادة (٢٣) من قانون ديوان المحاسبة بإختصاصه بفحص ومراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية بالنسبة للشركات والمؤسسات العامة التي يكون للدولة أو أحد أشخاص القانون العام حصة في رأس مالها لا تقل عن (٥٠٪) أو تضمن حداً أدنى من الأرباح، وكذلك للمنشآت التابعة لها والتي تزاوّل نشاطاً تجارياً أو صناعياً، وذلك وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات العامة في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوّل فيه حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها (١). ويتولى الديوان تحقيق رقابة فعّالة على الأموال العامة (٢) كما يمارس رقابته المالية على الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة، والبلديات ذات الشخصية المعنوية العامة، الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها بما لا يقل عن (٥٠٪) منه أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح (٣).

وبوجه عام يتولى الديوان مراقبة تحصيل إيرادات الدولة، وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها (٤). وقد تكون رقابة ديوان المحاسبة على أموال المرافق العامة الاقتصادية سابقة، بحيث تلزم الجهة المعنية بالألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رأى إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على ترخيص من الديوان إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر (٥).

وأما الرقابة اللاحقة فيتحقق الديوان من أن النفقات العامة قد أنفقت في الأغراض التي خصصت لها، والتأكد من أن الجهات المختصة بالجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحققاتها وتوريدها للخزانة العامة (٦).

- ١ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والصادر في (٧) يوليو ١٩٦٤.
- ٢ المادة (٢) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤.
- ٣ المادة (٥) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤.
- ٤ المادة (٦) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤.
- ٥ المادة (١٣) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤.
- ٦ المادة (٨، ١٣) من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ الكويتي.

الفرع الثاني دور الجهاز المركزي للمحاسبات المصري

يلعب الجهاز المركزي للمحاسبات المصري دوراً بارزاً وهاماً في مجال خصخصة المرافق العامة الإقتصادية ، فالجهاز شريك أساسي للحكومة في عملية الخصخصة وبيع القطاع العام منذ عام ١٩٩٧ وحتى وقتنا الراهن، ويبدو جلياً هذا الدور في المجالات الآتية (١) :

(١) مجال تقويم برنامج الخصخصة :

- أ- دراسة مدى توافر الشروط والضوابط اللازمة لنجاح برنامج الخصخصة وتقديم المقترحات بشأنها خاصة فيما يتعلق بالتدرج في تنفيذ البرنامج.
- ب- يقوم الجهاز بدراسة وتحليل مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة سواء لتهيئة المرافق العامة الإقتصادية للخصخصة أو لتهيئة البنية الإقتصادية المناسبة لنمو النشاط الخاص أو زيادة الاستثمارات.
- ج - دراسة وتحليل برنامج الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالبطالة والاحتكارات.

(٢) في مجال تنفيذ برنامج الخصخصة :

- أ. مراجعة الأسس التي استند إليها قطاع الأعمال العام في اختياره لآلية الخصخصة المناسبة لكل مشروع.
- ب. متابعة التنفيذ طبقاً للمراحل الزمنية التي حددها قطاع الأعمال العام.
- ج. في حالة البيع الكلي أو الجزئي للمرافق العامة الإقتصادية أو المشروعات العامة يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكد من سلامة الإجراءات وفقاً للضوابط المقررة.
- د. الرقابة على سلامة التصرفات للتأكد من عدم إساءة استعمال السلطة.

(٣) الرقابة على مساهمة المال العام في المشروعات المشتركة:

يمارس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على مساهمة رأس المال العام في المشروعات المشتركة، وذلك من خلال الرقابة على الشخص العام المساهم في هذه المشروعات ويقل دوره تدريجياً بإتجاه الحكومة إلى بيع نصيبها في أسهم الشركات المشتركة.

(٤) الرقابة على المشروعات التي يتم خصخصتها:

يمارس الجهاز رقابة على هذه المشروعات حيث يقوم خبراء بمراجعة تقييم أصول المشروع قبل نقل ملكيته للقطاع الخاص (٢)، وتمتد رقابة الجهاز بعد نقل المشروع للملكية القطاع الخاص، حيث يقوم الجهاز بالمراجعة ويختلف هذا الدور حسب طبيعة الخصخصة فقد تكون كلية أو جزئية:

١ د. جيهان حسن خليل، المرجع السابق، ص ٢٥٠ وما بعدها.
٢ مثال ذلك: قيام الجهاز المركزي بكافة عمليات التقييم لشركات التأمين المملوكة للدولة والتي سيتم خصخصتها. ويسير مراقبي الجهاز وفق مناهج محددة. (١) منهج التصفية، (٢) منهج رسم الأرباح المستقبلية، (٣) منهج خصم التدفقات النقدية: وهذه الرقابة تمثل أهمية كبيرة جداً، وذلك حتى لا تحدث المجاملات والمحسوبية عند البيع، أنظر: د. جيهان حسن خليل، المرجع السابق، ص ٢٥٢.

أ) حالات البيع الجزئي:

بيع جزء من نصيب الدولة في رأس مال الشركة العامة بحيث تظل الدولة مالكة للنسبة القانونية (٥١٪) من رأس المال، وفي هذه الحالة تظل الشركة أو الهيئة خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها شركة عامة. بيع جزء من نصيب الدولة في رأس المال بنسبة (٢٥٪) بحيث يصبح الاستثمار الحكومي في الشركة يزيد على ٢٥٪، وهنا تخضع الشركة لرقابة شاملة من عضو الجهاز بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات من قبل الجمعية العمومية للمستثمرين بالشركة لتدارك أي انحراف في النشاط، وهذا يفيد المستثمر كما يفيد الحكومة. بيع جزء من نصيب الدولة في رأس المال بحيث ينخفض نصيبها إلى أقل من ٢٥٪ من رأس المال، ففي هذه الحالة تتم الرقابة على مساهمة المال العام في هذه الشركة من خلال الشخص العام المساهم.

ب) حالات البيع الكلي:

إذا كانت الخصخصة كلية يلاحظ أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى التقييم والتأكد من سلامة أساليب التقييم ووضع التصور النهائي للقيمة العادلة لثمن البيع ثم مراقبة تنفيذ بنود التعاقد بين المستثمر أو المشتري وبين الحكومة لضمان جديته ويسرع بإبلاغ المسؤولين، وأن هناك مستثمرين قد استجابوا واستكملوا بقية إجراءات الخصخصة بجدية، وبعد ذلك يتوقف دور الجهاز تماماً بمجرد انتقال المرفق العام إلى القطاع الخاص. ويبدو لي أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المالية تكاد تنعدم بعد انتشار الخصخصة في مصر، وبمعنى أدق بعد البيع الكلي وتبقى له الرقابة القانونية فقط، وذلك على عكس ما هو حادث بالنسبة لشركات قطاع الأعمال، حيث نص القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ في المادة (٣٥) منه على أن «يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أداؤها طبقاً لقانونه» (١).

١ وفي ذات السياق نجد أن المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام تنص على "أن يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته بشأن الرقابة على الشركات القابضة والشركات التابعة لها ويقوم بتقويم أداؤها وفقاً لأحكام قانونية".

خاتمة

انصبت هذه الدراسة على النظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية، فقد تناولنا بشكل مختصر تعريف المرافق العامة الاقتصادية وذكر عناصرها، ثم تم البحث بشكل مستفيض للطبيعة القانونية لأموال المرافق العامة الاقتصادية، مع استعراض الاتجاهات الفقهية بشأن هذه الأموال، ثم قمنا ببيان المعيار المميز لأموال المرافق العامة الاقتصادية، في التشريعين الكويتي والمصري، هذا وتطرقنا بعد ذلك للقواعد الخاضعة لها أموال المرافق العامة الاقتصادية، وذلك من خلال تناولنا للقواعد العامة لأموال المشروعات العامة، وتطور نظامها القانوني، ثم تناولنا بشكل مختصر تعريف الخصخصة، ثم تم البحث أخيراً في تأثير الخصخصة على رقابة الدولة لأموال المرافق العامة الاقتصادية، وذلك من خلال استعراضنا للرقابتين البرلمانية والمالية على الأموال العامة في ضوء سياسة الخصخصة.

وعلى ضوء الهدف المحدد لهذه الدراسة والموضوعات التي تناولتها، فقد انتهت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج المنطقية والتي ترتب عليها عدد من التوصيات الواقعية، يمكن أن نجملها فيما يلي:

أولاً: نتائج الدراسة:

١. تبين من الدراسة المقارنة أن الهدف الرئيسي للدول من إنشاء المرافق العامة الاقتصادية تحقيق التنمية، ولتوفير الخدمات للأفراد كالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات، أو لتحقيق غايات سياسية كإنشاء مؤسسة الطيران، ومعرفة نوع المال تعد من المسائل الهامة، لاسيما بعد توسع مفاهيم الخصخصة وعودة هيمنة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي في الدول المختلفة.
٢. توصلت هذه الدراسة إلى أن المرافق العامة الاقتصادية لا بد وأن تخضع ولو جزئياً لقواعد القانون العام حتى تستطيع الدولة الهيمنة عليها، لكن خضوعها هذا لا يعد عنصراً من عناصر المرفق وإنما هو نتيجة من نتائج اكتساب المرفق الاقتصادي صفة المرفق العام.
٣. أكدت هذه الدراسة أن النظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي يختلف تبعاً لإختلاف طبيعة أموال المرفق، فهذه الأخيرة ليست على درجة واحدة، فقد تكون أموالاً عامة (الدومين العام)، وقد تكون مالاً خاصاً تملكها المرافق ملكية عادية كملكية الأفراد لأموالهم ويطلق عليها (الدومين الخاص).
٤. أكدت هذه الدراسة أيضاً أن النظام القانوني لأموال المرفق العام الاقتصادي يختلف تبعاً لتنوع طريقة إدارته، سواء تم إدارته بطريقة الاستغلال المباشر، أو بطريقة المؤسسات والهيئات العامة.
٥. أوضحت هذه الدراسة حدوث تطورات خاصة بالنظام القانوني لأموال المشروعات العامة، فلم يعد مبدأ عدم جواز التصرف في هذه الأموال يطبق بصورته الجامدة، وإنما أصبح يحتمل بعض مظاهر الخروج عليه، ومن ذلك الخروج على مبدأ جواز الحجز على الأموال العامة، وإنشاء حقوق إرتفاق للغير على الأموال العامة، والإعتراف بإنشاء حق عيني لشاغلي الأموال العامة.

ثانياً: توصيات الدراسة:

١. يجب فرض الحماية القانونية وبالشكل الصحيح على أموال المرافق العامة الاقتصادية باعتبارها أموالاً عامة، وتتمتع بذات الحماية القانونية التي تتمتع بها أموال المرافق العامة الإدارية، وذلك من خلال وضع الضوابط

المنظمة لمشاركة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، مثل وضع حد أدنى للأرباح التي يلتزم المستثمر الأجنبي باستثمارها داخل الدولة، وبما لا يتعارض مع تشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية وبالأخص الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

٢. ضرورة أن تقوم حكومتي الكويت ومصر بإزالة كافة القيود التي تعوق كفاءة المرافق العامة الاقتصادية، بل وإعادة هيكلة هذه المرافق، واستبقاء فكرة المرفق العام بالمفهوم التقليدي قاصراً على المرافق الاستراتيجية كالقضاء والدفاع والأمن، هذا مع العمل على تحديث وتطوير أساليب إدارة هذه المرافق لرفع كفاءتها.

٣. ضرورة قيام أعضاء البرلمان المصري والبرلمان الكويتي بتنفيذ الدور الرقابي، لا أن يقوموا بتغليب الدور التشريعي على حساب الدور الرقابي، ويتمثل هذا الدور الرقابي في فحص ومراقبة نشاط المؤسسات العامة، وتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية للمرافق العامة الاقتصادية.

٤. ضرورة إيجاد آلية عادلة وناجزة وفعّالة ومحايدة تضمن سرعة فض المنازعات الاقتصادية التي ربما تثور، فنرى ضرورة إيجاد محاكم اقتصادية في الكويت على غرار ما حدث في مصر.

٥. ضرورة أن يكون الهدف من الخصخصة - في رأينا - هو التحول من اقتصاد توزيع الثروة وهيمنة أقلية من التجار على الخدمات والأنشطة الحيوية إلى اقتصاد خلق الثروة وتحول الفرد إلى عنصر منتج يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وهذا كله تحت إدارة حكومية فعّالة، وذلك حتى يمكن للقطاع الخاص أن يقود الاقتصاد الوطني إلى حالة النمو والازدهار.

٦. يتعين على الدائرة الإدارية في الكويت والقضاء الإداري المصري تطوير المبادئ التي تحكم المنازعات الاقتصادية، فمن الملاحظ أن أغلب الأحكام التي تصدر تستند إلى المبادئ التي أرسنها محكمة القضاء الإداري في منتصف القرن الماضي.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية :

١- الكتب:

- د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، المال العام في القانون المصري والمقارن، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الجزء الأول، ١٩٧٥.
- د. إبراهيم محمد الحمود، المالية العامة للدولة، دراسة تأصيلية في فقه المالية العامة والقوانين المالية مع الإشارة لمالية دولة الكويت، جامعة الكويت، كلية الحقوق، الطبعة الأولى، ٢٠١٢.
- د. أحمد حمد الفارسي، د. خليفه الحميدة، القانون الإداري، جامعة الكويت، كلية الحقوق، ٢٠١٥.
- د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٩.
- د. ثروت بدوي، النظرية العامة للعقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٦.
- د. جيهان حسن خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠.
- د. سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٨.
- د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الخط العربي، القاهرة، ١٩٧٩.
- د. عزيزة الشريف، د. يسري العصار، القانون الإداري، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩.
- د. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٣.
- د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٢.
- د. محمد محمد عبداللطيف، التطورات المعاصرة للمرافق العامة الإقتصادية، مجلة النشر العلمي، جامعة الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩.
- د. محمد محمد عبداللطيف، القانون العام الإقتصادي، دراسة مقارنة، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، الطبعة الأولى، ٢٠١٠.

٢- الرسائل العلمية:

- د. محمود أحمد سليمان البراشدي، النظام القانوني لأموال المرفق العام في ظل سياسة الخصخصة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ٢٠٠٩.
- د. حمد زيدان نايف محمد العنزي، الحماية الجنائية للمرافق والأموال العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ١٩٩٥.
- د. عزت فوزي حنا، المرفق العام الإقتصادي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ١٩٩٢.

د. هشام البدوي، الدور التشريعي للبرلمان في المجال المالي، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، ١٩٩٧.

٣- الأبحاث العلمية:

د. محمد محمد عبداللطيف، الحماية الدستورية للمالية العامة، بحث مقدم إلى مؤتمر حماية الأموال العامة، جامعة الزقازيق، فرع بنها، ٢٠٠٤.

٤- الأحكام والفتاوى المصرية:

الدعوى رقم (٤) لسنة (٢) ق. دستورية جلسة ١٩٧٢/٧/١، المجموعة الدستورية، ج ١، المحكمة الدستورية العليا. ج.م.ع (٧) من أغسطس ١٩٩٦، الفتوى رقم ٧١٧، ملف رقم ٢٣٧٢/٢/٣٢، المجموعة، السنة ٥٠. ج.م.ع. ٢٢ يونيو ١٩٦٣، الفتوى رقم ٩٨١، ملف ٦٥/١/٤٧، المجموعة، ١ لسنة ١، مجلس الدولة المصري.

ثانيا: المراجع الفرنسية:

١- الكتب الفرنسية:

Auby (J.M.). et DUCOS – ADER. Grands Services Publics et entreprises nationales. 1975. T. 1.
Bureau. De recherché geologiques et minieres. RFDA. 1988.
Blanc (F.). L'insaisissabilité des établissements publics industriels et commerciaux. éléments pour une évolution. RDP. 2009.
Chapus (R.). Droit Administrative Général. T. II. ed.. 1997.
DE LAUBADERE (A.) VENEZIA (J.C.). GAUDMET (Y.). Traite de droit administratif. T. 1. LGDJ. 1996.
Fatome (E.) et Terneyre (Ph.). Chronique de législation. Droites réels sur le domaine public de l'Etat. AJDA. 1995.
Fournier (A.) et Jacquot (H.). Un nouveau statut pour les occupants du domaine public. AJDA. 1994.
Gaudment (Y.). Les Droit réels sur le domaine public. AJDA. 2006.
Maestre (J.C.). Le Controle des budgets des etablissements d'enseignement. A.J.. 1987.
Maugue (Ch.) et Bachelier (G.). Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques. 2006.
RIVRO. Le Regeme des Nationalisations. J. C. P.. 1948.

٢- أحكام القضاء الفرنسي:

C.C 25 juillet 2001.448 Dc. RDP.2001.p.1466.note lucaise.
CE. avis. 30 janv. 1992. EDCE. 1992. P. 401.
C.C. 9 JUIN 1992.309 DC.REC.P.66.
Cass. Soci.. 17 Avril 1991. Groupement des Assedic DE La region Parisienne C./ Cie Air France. J.C.P.. 1991. P. 3.
Cass. Civ.. 3 mai 1988. consorts Renault C./ EDF. CJEG. 1988. P. 50. rapp. Sargos.
Cass. Civ.. 1er Dec. 1987. Bull. N. 1. 348. P. 249. J.C.P.. 1981. II. 21113. note (B.) Nicod.
CE. 6 mai 1985. Association Eurolat et Credit foncier de France. RFDA. 1986. P. 21. Concl. B. Genevois.

CE. 23 oct. 1963. SNCF. Rec.. P. 497; AJDA. 1964. P. 321. note Laporte; RDP. 1963. P. 1191. Concl. Braibant; 4 fev. 1970. Minsitre de l'equiplemnet C./SNCF. Rec.. P. 84. AJDA. 1970. II. P. 421. note Duffau.

CE. 7 nov. 1962. EDF C. Faivre. AJDA. 1963. II. P. 184. note A. de Laubadere.

CE. Ass.. Ler sep. 1950. Rec.. P. 595; D. 1952. note L'Huillier. S. 1951. 3. 61. note Boulouis; CE. 7 nov. 1962. EDFC / Consorts Jacquet. AJDA. 1963. II. 184. note (A.) de Laubadere.